

第5編 ■ 社会法益に対する罪

第1章 公衆の平穏及び安全に対する罪／第1節 騒乱の罪 第2節 放火及び失火の罪

刑法
No.350

H19-3

(配点：2)

月 日

月 日

教授と学生A及びBが、刑法第110条の建造物等以外放火罪の成立要件である「公共の危険」に関する議論をしている。次の【発言】中の①から⑤までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【発言】

教授 刑法第110条第1項に規定される建造物等以外放火罪は、条文上「公共の危険」の発生を要求していますが、Aさんは、この「公共の危険」の内容について、どのように考えますか。

学生A 私は、「公共の危険」とは、①(a. 現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等に対する延焼の危険・b. 現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等に限定せず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険)をいうと理解しています。

教授 Aさんの考え方は、判例の立場と同じですね。

学生A はい、そうです。

学生B 私は、判例の立場には反対しています。Aさんの考え方だと、例えば、犯人が小さなゴミ箱1個に放火した際、たまたまその横に置き忘れられていた不特定人の小さな物品1個に延焼の危険が発生しても、「公共の危険」が発生したとされかねず、不当な結果にならないでしょうか。

学生A 私の立場に立っても、各事案ごとの具体的状況の中で火災に基づく危険の拡大作用が認められるかどうかを判断することになると思います。

教授 次に、建造物等以外放火罪が成立するためには、「公共の危険」の認識が必要かどうかについて議論しましょう。

学生B 私は、「公共の危険」の認識は、②(c. 必要・d. 不要)と考えます。なぜなら、③(e. 刑法第110条の条文の文言が「よって公共の危険を生じさせた」となっている・f. 責任主義の原則から考えて結果的責任は否定されるべきである)からです。

学生A しかし、あなたの考えでは、④(g. 實際上、現住建造物等放火罪又は他人の所有の非現住建造物等放火罪の未必の故意が認められてしまう・h. 基本犯が不可罰である行為の結果的加重犯を認めることになる)という問題が生じませんか。

学生B 私の立場でも、刑法第110条における「公共の危険」の認識内容について、延焼の危険の認識と区別することは可能だと考えます。

教授 この点に関するあなたの考え方は、判例と同じですか。

学生B 私は、判例に⑤(i. 賛成・j. 反対)する立場です。

- ①a②d③f④h⑤i
- ①a②d③e④g⑤j
- ①b②c③e④h⑤j
- ①b②d③e④g⑤i
- ①b②c③f④g⑤j

本問は110条1項の「公共の危険」の内容、及び「公共の危険」の認識の要否に関する見解の対立を問うものである。

まず、110条1項の「公共の危険」の内容について、判例は、「刑法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である」としている（最決平15.4.14、百選Ⅱ85事件）。

次に、公共の危険の認識の要否について、認識を必要とする見解は、近代刑法における責任主義を重視して、結果的責任を極力否定すべきであることを理由に挙げる。

これに対し、公共の危険の認識を不要とする見解は、110条1項が「よって公共の危険を生じさせた者」という結果的加重犯的な規定の仕方をしていることを理由に挙げる。公共の危険の認識が必要であるとする見解に対しては、公共の危険の故意と現住建造物等への延焼の認識は区別できないのではないか、公共の危険の認識があれば（延焼の危険としての公共の危険の発生により）現住建造物等放火罪等の未遂が成立することになり、109条2項、110条の適用領域が事実上なくなってしまうのではないかという批判がある。

この点について、判例は、「刑法110条1項の放火罪が成立するためには、火を放って同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが、焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はないと解すべきである」として、公共の危険の認識を不要としている（最判昭60.3.28、百選Ⅱ86事件）。

① b

教授の第2発言に、「Aさんの考え方は、判例の立場と同じですね。」とある。判例は、「刑法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である」としている（最決平15.4.14、百選Ⅱ85事件）。したがって、①はbが正しい。

② c ③ f

110条の「公共の危険」の認識の要否については見解が分かれる。「公共の危険」の認識を必要とする見解（②c）は、結果的責任は近代刑法における責任主義と相容れないことをその根拠としており、③fと対応する。これに対し、「公共の危険」の認識を不要とする見解（②d）は、110条1項が「よって公共の危険を生じさせた者」という結果的加重犯的な規定の仕方をしていることから、結果的加重犯における重い結果としての危険の発生の認識の要否の問題と結び付けて論じることが多く、②dと③eが対応する。そして、この段階ではいずれの組合せが正解かは明らかではない。しかし、後述のように④で学生Bは公共の危険の認識を必要とする見解を採ることから、②はc、③はfが正しい。

④ g

学生Bの第3発言に、「『公共の危険』の認識内容について、延焼の危険の認識と区別することは可能」とある。公共の危険の認識が必要であるとする見解に対しては、公共の危険の故意と現住建造物等への延焼の認識は区別できないのではないか、公共の危険の認識があれば（延焼の危険としての公共の危険の発生により）現住建造物等放火罪等の未遂が成立することになり、109条2項、

110条の適用領域が事実上なくなってしまうのではないかという批判がある。学生Bの第3発言はかかる批判に対する反論であるから、この時点で学生Bが公共の危険の認識を必要とする見解を採ることがわかる。したがって、これを批判するAの発言④はgが正しい。

⑤ j

学生Bは④で検討したように公共の危険の認識を必要とする見解を採る。そして、判例は、前述のように公共の危険の認識を不要としているため（最判昭 60.3.28、百選Ⅱ86事件）、⑤はjが正しい。

以上により、①から⑤までの（ ）内から適切な語句を選んだ組合せとして正しいのは①b②c③f④g⑤jであり、したがって、正解は肢5となる。